

刑法
No136

H22-10

(配点: 2)

月 日

月 日

中止犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 強盗予備罪について中止犯が成立し得る。
2. 犯罪を共同して実行する旨の共謀が成立した後に、共犯関係からの離脱が認められる場合、離脱者には、常に中止犯が成立する。
3. 行為者が、幼児を山中に連れて行き置き去りにしたが、その後、後悔して山中に戻り、衰弱した幼児を病院に運び込んで医師の治療を受けさせ、これにより幼児の容体が快復した場合には、遺棄罪の中止犯が成立し得る。
4. 中止犯が成立するには、必ずしも行為者が単独で結果発生を防止する必要はない。
5. 中止犯が成立する場合、必ずその刑が免除される。

№136	中止犯	正答率
H22-10	正解 4	92%

1 誤っている

最大判昭 29.1.20 (百選 I 72 事件)。本記述では、強盗予備罪について中止犯が成立し得るかが問題となる。この点、被告人が、共犯者と相談の上、被害者方で強盗をしようと企て、それぞれが出刃包丁等を携えて被害者方に赴いたという事案において、判例は、被告人らの行為を強盗予備の共同正犯とした上で、被告人が、自己の罪業の深さに気づき、無意識に一目散に自宅へ帰ったという事情があるとしても、「予備罪には中止未遂の観念を容れる余地のないものである」として、強盗予備罪における中止犯の成立を否定している。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、43 条ただし書の文言が、実行に着手した後の未遂を前提としてしていると解されていることに加え、予備の段階に達すれば、たとえ予定したことの一部であっても、個別の行為が予備としての評価を受けるため、予備はそれ自体で完結するものであり、予備罪については中止犯を観念する余地がないということを挙げている。よって、強盗予備罪について中止犯は成立しない。

2 誤っている

本記述では、犯罪を共同して実行する旨の共謀が成立した後に、共犯関係からの離脱が認められる場合、離脱者には、常に中止犯が成立するかが問題となる。共犯関係からの離脱とは、共犯者の 1 人が犯罪遂行過程で犯意を放棄し、以後、共犯者との犯罪実行を中止することをいう。共犯関係からの離脱は、共犯関係の解消を意味するから、離脱者には離脱までの行為について罪責を負う。そして、離脱者が、離脱までの行為について罪責を負う場合、別途、離脱までの行為につき、中止犯が成立するか否かが問題となる。まず、本記述における離脱が、犯罪実行着手前の離脱である場合、予備罪につき規定の無い犯罪については、離脱者は何らの罪責を負わず、中止犯は問題とならない。予備罪につき規定のある犯罪については、離脱者は、離脱以前の行為につき、予備罪の共同正犯の罪責を負う。この場合、離脱が「自己の意思」(43 条ただし書)によるときは、予備罪の中止犯の成否が問題となる。この点について判例は、少なくとも強盗予備罪について、「……予備罪には中止未遂の観念を容れる余地のないものである」(最大判昭 29.1.20、百選 I 72 事件)として、中止犯の成立を否定している(肢 1 参照)。よって、犯罪実行着手前の離脱である場合、離脱者には常に中止犯が成立するとはいえない。次に、本記述における離脱が、犯罪実行着手後既遂以前の離脱である場合、離脱以前の行為につき、未遂罪の罪責を負う。その上で更に中止犯の成立が認められるためには、別途「自己の意思により」、「犯罪を中止した」といえることが必要である(同条ただし書)。よって、犯罪実行着手後の離脱である場合、離脱者には常に中止犯が成立するとはいえない。

3 誤っている

中止犯とは、「犯罪の実行に着手し」た後、「自己の意思により犯罪を中止した」場合である(43 条ただし書)。したがって、未遂犯のうちで、自己の意思により犯罪を中止した場合が中止犯である。遺棄罪(217 条)における「遺棄」とは、要保護者を安全な場所から危険な場所に移すことをいう。そして、判例は、217 条の罪は、扶助を必要とする老若、幼者、不具者又は病者を遺棄することによって直ちに成立し、現実生命身体に対する危険を発生させたことを必要としないとして、遺棄罪を抽象的危険犯とする(大判大 4.5.21)。よって、遺棄罪は、要保護者を安全な場所から危険な場所に移した時点で、既遂に達する。本記述では、幼児を山中に連れて行き置き去りにしており、「幼年の……ために扶助を必要とする者」を、安全な場所から、幼児にとって危険な場所である「山中」に移したといえる。よって、幼児を山中に連れて行き置き去りにした時点で、遺棄罪の既遂犯が成立する。以上を前提とすると、幼児を山中に連れて行き置き去りにした後に、後悔して

山中に戻り、幼児を病院に運び込んで医師の治療を受けさせ、これにより幼児の容体が快復したとしても、既に既遂犯が成立している以上、未遂犯を前提とする中止犯は成立しない。よって、遺棄罪の中止犯は成立しない。

4 正しい

大判昭 12.6.25。本記述では、中止犯が成立するためには、行為者が単独で結果発生を防止する必要があるかが問題となる。この点、犯人が、放火後、よろしく頼むと叫んだのみで逃走した事案において、判例は、中止未遂というには、少なくとも犯人自ら結果の発生を防止するか、又は自ら防止したと同視するに足りる努力を払わねばならないから、放火後火勢を恐れ、よろしく頼むと叫び逃走するのは、中止犯とはいえないとして、中止犯の成立には、必ずしも行為者が単独で結果発生を防止する必要のないことを前提としている。その理由として、判例は、「自己の信念により中止することを正当なりと決心しその犯罪結果の進行を中断すれば、もって中止未遂となるのみならず、犯罪の結果を自己の信念により中止する以上、直接之を行うと又第三者をして自己に代ってこれをなさしむるとを区別すべきものではない」としている。よって、中止犯が成立するには、必ずしも行為者が単独で結果発生を防止する必要はない。

5 誤っている

43 条ただし書。同条ただし書は、「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減輕し、又は免除する。」と規定し、中止犯成立の効果として必要的減免を定め、自己の意思によらない事情により犯罪が完成しなかった障碍未遂の効果がたかだか裁量的減輕であるのとは明確に区別している。よって、中止犯が成立する場合、その刑が減輕、又は免除される。